

1522423-74.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... trazendo consigo, para fins de tráfico, três porções de "maconha". Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 14h, na Estrada da Vila Jaguará, nº 162, o acusado, estaria mantendo em depósito e cultivando, para fins de tráfico, duzentas plantas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522423-74.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522423-74.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSWALDO ESPOSITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de OSWALDO ESPOSITO, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal, e com o art. 1º, da Lei nº 11.464/07. Consta da exordial que no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 13h, na Rua Barbalha, altura do nº 82, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, três porções de "maconha". Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 14h, na Estrada da Vila Jaguará, nº 162, o acusado, estaria mantendo em depósito e cultivando, para fins de tráfico, duzentas plantas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 358/360. O laudo de exame pericial do veículo apreendido está a fls. 361/371. A denúncia foi recebida (fls. 168/169) providência ratificada a fls. 215/216. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 389), ofertou defesa preliminar (fls. 184/205). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas e informantes do juízo sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno as I. advogadas do acusado, preliminarmente, atacara a legalidade da prisão em flagrante do réu aduzindo questões como invasão de domicílio e rompimento da cadeia de custódia das provas. No mérito, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, bem como defendendo tese de que a droga, tanto já preparada

para consumo, quanto as plantas, serviriam à confecção de óleo para fins medicinais para uso dele e de seus pais. No mais, subsidiariamente, pugnou-se pela desclassificação da conduta para porte ilícito de entorpecentes, bem como com relação ao afastamento da circunstância agravante apontada na denúncia, no mais tecendo-se considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A questão atinente à prisão em flagrante do réu já foi analisada em juízo antes mesmo da distribuição do feito a esta Vara Criminal não havendo que se cogitar de nulidade. A mera alegação do réu quanto à ausência de autorização de entrada da polícia em imóvel onde se praticava crime não afasta a legalidade da conduta dos agentes públicos. Ademais, por isso mesmo, era imprescindível ordem judicial. O réu, ao ser preso em via pública, já possuía entorpecente. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Willians e Emerson relataram que em patrulhamento de rotina receberam informação do serviço reservado da Polícia Militar dando conta do envolvimento de um homem num veículo preto, de modelo Tiida, que havia deixado uma residência onde haveria entorpecente. O réu foi abordado não muito longe da casa onde posteriormente plantas de “maconha” foram apreendidas. No momento da abordagem, na cintura do réu, duas porções da referida droga foram encontradas e, ato contínuo, uma terceira, idêntica às duas primeiras, foi também apreendida no interior do carro próxima ao câmbio. O policial Willians referiu-se a três pacotes médios e não a porções individualizadas. No veículo, também próximo ao câmbio, uma chave de casa foi localizada tendo o réu conduzido os policiais a uma casa que não era habitada, mas que servia apenas ao cultivo de cerca de duzentas plantas de “maconha”. Os milicianos referiram a presença, no imóvel, de fertilizantes, bem como embalagens plásticas e de papel. O réu, ao ser abordado, afirmou que usava “maconha” para fins medicinais, mas não forneceu maiores detalhes. Willians referiu ter na casa indicada localizado “alguns frascos de óleo”, bem como outras coisas de que não se recordou. Willians também afirmou que no carro do réu havia dois frascos de fertilizante importado comumente usado para cultivo de plantas em estufa. Os pais do acusado, Osvaldo e Neide, informaram fazer de longa data uso de óleo de canabidiol eis que sofrem de depressão. Informaram que o produto é muito caro, que não reúnem condições de adquiri-lo no mercado, razão porque seu filho passou a cultivar plantas de “maconha” para extração do óleo. Neide esclareceu que seu filho trabalha em sua casa vendendo artigos para jardinagem, bem como vasos de feltro que ela confecciona. Neide afirmou que sofre de depressão desde antes de 2000, ano em que se mudou para San Diego, onde fazia uso do óleo de canabidiol. Esclareceu que o réu alugou a casa onde plantava “maconha” em janeiro ou fevereiro de 2020. Fernanda, também inquirida na qualidade de informante do juízo por ser esposa do réu há quinze anos, disse que seu marido, desde a adolescência, fumava “maconha”. Seu intento inicial era “recreativo”, mas depois, em razão de ansiedade, depressão e insônia, passou a fazer uso da droga em forma de óleo. Disse que Oswaldo plantava “maconha” havia dois anos numa casa alugada. Disse que nunca esteve na casa. Afirmou que seu esposo trabalha vendendo vasos. As testemunhas Omar e Samyr, respectivamente Delegado de Polícia e policial civil, confirmaram a existência das inúmeras plantas de “maconha” na casa cuja posse era exercida pelo réu, que segundo eles, na Delegacia de Polícia informou que fazia uso medicinal. Disseram não ter encontrado petrechos ou máquina relativa à extração de óleo de “maconha”. Interrogado em juízo Oswaldo confirmou que no dia dos fatos, ao ser abordado em via pública a bordo de seu carro, possuía duas porções de “maconha” que estava levando para a casa de sua mãe. Indagado sobre a razão de estar levando a droga para a casa de sua mãe disse que iria com ela fazer inalação, sendo que neste momento nada referiu a respeito de extração de óleo. Esclareceu que não morava com a mãe, mas que em sua casa fazia extração do óleo de “maconha” para fins medicinais, já que seu pai já sofreu de câncer, bem como afirmou que, assim como sua mãe, sofre de ansiedade e depressão. Disse que já moraram na Califórnia, Estados Unidos, local onde passaram a fazer uso de “cbd”, produto que melhorou a qualidade de vida dos familiares. Disse que, de cinco a seis meses antes de ser preso, alugou uma casa a

fim de cultivar plantas de “maconha” para produzir o referido óleo. Afirmou nunca ter vendido ou distribuído o produto a terceiros, mas apenas produzia óleo para seu consumo e seus pais. Disse que na casa de sua mãe, após colher flores, secá-las e triturá-las, as congelava misturando-as, posteriormente, a álcool de cereais também mantido em baixas temperaturas. A partir daí usava filtro de café e mistura o produto a óleo de côco. Esclareceu que não possuía autorização para cultivar “maconha”, mas apenas “receita médica”. Afirmou que os policiais, ao ser abordado, determinaram que digitasse um número em seu telefone e a partir disso descobriram onde era a casa onde estavam as plantas. Sendo assim, ficou claro que o réu pretendeu esconder o tal imóvel ao invés de desde logo informar à polícia suas supostas legítimas intenções. Disse que chegando na casa havia inúmeras viaturas policiais e que a porta estava aberta. Esclareceu que em dois quartos fazia o cultivo das fases vegetativa e de floração. Para tanto usava luz. Disse que a quantidade de plantas era necessária em razão da fase das plantas, isto é, para que fosse provida a quantidade de “remédio” necessária a si e seus pais. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. O uso da “cannabis sativa L” para fins medicinais é objeto de estudo por cientistas havendo quem o recomende. Entretanto, a prática de cultivar plantas de “maconha”, bem como transportar a droga, ainda é crime no Brasil. Se o réu e seus familiares entendiam necessário o uso da substância para fins terapêuticos, deveriam ter buscado autoridade competente e, perante o Estado, deduzir pedido de utilização legal da substância. De fato o fizeram, mas tal autorização não afasta a ilegalidade verificada neste feito porquanto válida “ex nunc”. Se o réu visava buscar tal autorização e para isso precisava estar cultivando as plantas, não veio aos autos nenhum elemento comprobatório de que tenha dado início à distribuição de demanda nesse sentido. De fato, o réu fazia cultivo de “maconha” de forma clandestina e assim pretendia continuar, mas foi preso e depois disso, então, resolveu legalizar sua situação. E, nesse ponto, não se pode olvidar, transportava porções de “maconha”, de tamanho maiores, não as comumente individualizadas, em seu veículo. Sua mera alegação de que ia para a casa da mãe não é suficiente a afastar a ilegalidade da conduta, que é prevista em lei. Ademais, não há nos autos comprovação cabal de que o réu plantava “maconha” para esses fins não sendo hipótese de desclassificação da conduta como pretendem as combativas advogadas. A utilização das plantas para extração de óleo não está provada nestes autos, o que incumbia à defesa eis que essa é a base de sua tese absolutória. Tal prática requer o mínimo de aparato e conhecimento técnico. A defesa não produziu provas a esclarecer o local onde o réu extraia o óleo de “maconha”, bem como seria muito fácil comprovar que ele possuía petrechos para isso, o que é imprescindível à técnica mencionada. De outra banda, os inúmeros documentos fornecidos pelos médicos psiquiatras doutores Flávio e Maria Fernanda não comprovam a alegada destinação da exorbitante quantidade de plantas de “maconha” cultivadas pelo réu para fins medicinais. Os documentos apenas declaram ter, o acusado e sua mãe, afirmado perante os referidos

médicos que estavam a cultivar as plantas visando extrair óleo. A fls. 74 e 210 acostaram-se dois documentos emitidos pelo médico Flávio, ambos datados de 4 de setembro de 2020, isto é, antes do fato tratado nestes autos, apontando que Oswaldo usava “óleo de CBD”. A fls. 394 o doutor Flávio declarou, em 8 de dezembro de 2020, que o réu, havia dez anos, isto é, desde 2010, sentia ansiedade e tristeza. O tal documento visa, como os demais, fazer esta Magistrada acreditar que o réu passou a consumir “óleo de maconha” para fins medicinais. Entretanto, consta ter o réu, já em 2004, isto é, muito antes de começar a sentir ansiedade e tristeza, em tese cometido delito de porte ilícito de entorpecentes. Na ocasião, numa das Varas Criminais do Foro Regional da Lapa, foi agraciado com a transação penal. A fls. 395/401 há vários documentos do mesmo médico, Flávio, descrevendo que o réu fazia uso de “óleo de cbd”. No documento de fls. 406, curiosamente confeccionado em 11 de outubro de 2020, isto é, antes do crime tratado nestes autos, há menção de que o réu, por não ter condições de adquirir o óleo referido, produto que seria importado, passou a fazê-lo na forma artesanal. Consta: “informa que está fazendo

uso de óleo artesanal". O documento de fls. 407, bem semelhante ao de fls. 406, datado de 22 de outubro de 2021, revela ter o réu afirmado ao referido médico que "iniciou cultivo doméstico de cannabis e que do cultivo extrai o óleo de seu tratamento". A fls. 408/411 a médica Maria Fernanda referiu-se a declaração da mãe do réu, sua paciente, referindo também "início de cultivo e extração do óleo". Os documentos em análise, como já asseverado, só provam uma coisa: que o réu e sua mãe disseram aos seus médicos que usavam "óleo de maconha" e cultivavam plantas para este fim. Os mencionados profissionais não foram inquiridos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa no piso mínimo unitário legal. A confissão não servirá à atenuação das sanções em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser o réu primário e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 2 meses de reclusão e 417 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP. Defiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR OSWALDO ESPOSITO, qualificado nos autos, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 417 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal. Autorizo a incineração dos entorpecentes e das plantas oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Autorizo a devolução do veículo apreendido por não entender que sua aquisição ou sua utilização estavam ligadas ao delito ora punido. Autorizo também a devolução do dinheiro, do telefone, dos frascos de fertilizante e de gás apreendidos. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA